REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 24.11.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 9617/2023 RG e vertente

TRA

Parte_1 , elettivamente domiciliata in Roma, Via M.B. Tosatti 26, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cirilli che la rappresenta e difende per procura in atti (parte opponente).

E

CP_1 , elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (parte opposta).

FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha convenuto in giudizio l' *CP_1* rassegnando nei suoi confronti le seguenti conclusioni*: -Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito ogni avversa opinione respinta:1) Accertare i fatti per cui è ricorso e per l'effetto;2) Annullare l'avviso di addebito impugnato in uno con tutti gli atti precedenti, susseguenti,necessari e conseguenziali;Vinte le spese di lite con clausola di antistatarietà."*

L' *CP_1* si è costituito rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: "*In via preliminare: verificare la tempestività dell'opposizione e dichiarare il ricorso inammissibile per tardività dello stesso; Nel merito, in via principale, dichiarare la parziale cessata materia del contendere e respingere il ricorso di parte avversa in parte qua tenuto conto del provvedimento di sgravio, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, condannare parte opponente al pagamento della minor somma accertata in corso di causa oltre oneri accessori per legge sino al saldo. Con vittoria di spese."*

E' stato autorizzato il deposito di note.

Infine la causa, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con il deposito della presente sentenza contestuale, pubblicamente letta.

****

L'eccezione di inammissibilità/tardività dell'opposizione è infondata.

Infatti l'avviso di addebito è stato notificato il 7.2.2023 (circostanza che, contrariamente a quanto affermato dall' *CP_1* nelle sue note autorizzate è provata per tabulas, v. esito della spedizione di *Org_1* prodotta dal ricorrente) e l'opposizione è stata depositata telematicamente il 20.3.2023 (come risulta dalla consolle del giudice). Poichè l'ultimo giorno (il 40°), e cioè il 19.3.2023, cadeva di domenica (febbraio 2023 ha 28 giorni) il termine è prorogato per legge al giorno successivo e quindi l'opposizione risulta tempestiva.

Nel merito, e pretese dell' *CP_1* aventi ad oggetto contributi relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 02/2018 sino al 12/2021 (per un totale di € 16.309,42) si fondano (v. comparsa di costituzione) sulla circostanza che la parte ricorrente dovrebbe essere iscritta alla Gestione Commercianti in quanto socio ed amministratore unico della *Org_2*

[...]

Parte_1 ha proposto opposizione sostenendo che non vi sarebbe prova dello stesso presupposto di fatto di tale pretesa e che comunque sarebbe inammissibile il doppio versamento dei contributi alla Gestione separata *CP_1* e alla Gestione Commercianti.

Il compito del giudice è solo quello di accertare se l'avviso impugnato sia o meno legittimo, e quindi se negli anni dal 2018 al 2021 la sig.ra Pt_1 abbia svolto l'attività continuativa e prevalente che costituisce il presupposto dei contributi richiesti.

A sostegno di tale pretesa l' CP_1 si è limitato ad allegare, richiamando una nota dell'ufficio amministrativo, quanto segue: "*La materia del contendere verte sull'avviso di addebito n. 39720220025411380000, concernente Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro il miinimale, per il periodo intercorrente tra il 02/2018 e il 12/2021, per un importo complessivo pari ad euro 16.309,42 notificato al ricorrente in data 07/02/2023. Con riferimento al merito della pretesa contributiva, la scrivente Sede ha avuto modo di evidenziare, sulla base dei dati derivanti da* [...] Organizzazione_3 *che l'imputazione dell'attività della* Org_4 *alla ricorrente inizia il 21 febbraio 2018, data in cui è stata costituita la società medesima e all'interno della quale la ricorrente risulta aver acquisito fin dall'origine la qualità di socio unico e amministratore unico. In relazione al periodo di accertamento dell contestato, dal Prospetto* Org_6 *e dalle risultanze acquisite da* Org_7 *si accerta che la sig.ra* Parte_1 *ha prestato attività dipendente a tempo pieno e determinato dal 1/03/2019 al 31/05/2019 presso* [...] Organizzazione_8 *e, successivamente, attività dipendente a tempo parziale (80% del tempo pieno – 32 ore) dal 1/06/2019 al*

31/12/2019 presso Organizzazione_9

[...] *Si precisa che, pur a fronte di apposita comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro riferita anche ai mesi gennaio e febbraio 2019, non risultando flussi uniemens trasmessi, l'arco temporale preso in considerazione per le opportune valutazioni in ordine al concomitante lavoro autonomo è limitato ai mesi da marzo a maggio 2019. Ed invero, risultando solo per tali mesi rapporto di lavoro a tempo pieno, la scrivente Unità Operativa ha ritenuto di procedere con lo sgravio solo degli anzidetti mesi e non anche per i periodi coperti da rapporto di lavoro part time, tenuto conto dell'assenza di personale alle dipendenze della società. Al di fuori del periodo da ultimo considerato, dalle verifiche effettuate è emerso che la ricorrente non svolgeva altre attività di lavoro prevalenti e che la* Org_4 *non ha mai occupato, né tutt'ora occupa, personale dipendente. Pertanto, anche valutata l'assenza di dipendenti/collaboratori e di dirigenti o preposti a cui delegare l'esercizio delle funzioni direttive, la ricorrente nel periodo di accertamento si è occupata direttamente e personalmente della gestione, direzione e organizzazione della società, assumendone la piena responsabilità. Ai sensi della circolare n.78/2013, dunque, sussistono i presupposti per l'iscrizione della Sig.ra* Parte_1 *alla Gestione Commercianti in qualità di titolare d'impresa. In ragione di tanto, a parere della scrivente sede, resta legittima l'iscrizione operata e dovuta la pretesa contributiva, eccezion fatta per il periodo 3-5/2019.*

Nonostante lo sgravio parziale, e quindi il riconoscimento della parziale infondatezza dell'originaria pretesa, l'CP_1 ha chiesto di rigettare l'opposizione senza essere in grado di specificare quali sarebbero state le attività svolte dalla ricorrente evidenziando che la sig.ra Pt_1 non avrebbe svolto alcuna diversa attività lavorativa nel periodo in contestazione.

In effetti, il problema resta sempre quello di stabilire se la ricorrente abbia svolto con carattere di prevalenza attività di partecipazione e gestione dell'azienda non essendo sufficiente la qualità di socio e neanche quella di amministratore.

Perché, se ciò non è avvenuto, nulla è tenuta a pagare la ricorrente, a prescindere dall'esistenza o meno di dipendenti della Organizzazione_4 , abbia o non abbia la stessa svolto qualche altra attività lavorativa nel periodo cui si riferisce.

In altre parole, l CP_1 ripropone la tesi che esisterebbe una sorta di presunzione semplice di svolgimento dell'attività necessaria a far nascere l'obbligo contributivo, ricavata dalla qualità di socio/amministratore e dall'assenza di altre contemporanee attività lavorative della ricorrente.

Tale assunto non può essere condiviso.

La disciplina dei presupposti dell'iscrizione alla gestione speciale commercianti dell'assicurazione generale obbligatoria ha subito modifiche di notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996. Un ruolo centrale è svolto dai commi 202 e 203 dell'art. 1, i quali, così recitano: "202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti.203. La L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, è sostituito dal seguente:L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;d)

siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività.

Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al

registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".

Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di socio e amministratore, poiché, rispetto alle previsioni della legge vigente, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a dipendenti, a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.

E ciò perché, come rimarcato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n. 3240, l'assicurazione obbligatoria "è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti

dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".

Alla luce di queste considerazioni, va ribadito il principio di diritto già espresso da Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835, secondo cui "*ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio e amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore*".

In sintesi, la Suprema Corte più volte precisato e ribadito sul punto che: "*perchè sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b),ossia la responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c), ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore* (Cass. 26 febbraio 2016 n.3835).

Del resto, non si comprende proprio quale sarebbe questa attività svolta dalla ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza, che l'*CP_1* non ha nemmeno indicato.

Spetta comunque all' CP_1 dimostrare i fatti che possono giustificare, anche nella sua stessa prospettazione, la pretesa contributiva in questa sede impugnata, non essendo sufficiente la semplice qualità di socio e/o amministratore della sig.ra Pt_2 .

Perchè, contrariamente a quanto sembra ritenere l' CP_1 l'onere della prova nella materia (l'opposizione a cartella e oggi ad avviso di pagamento va equiparata a quella a decreto ingiuntivo, v. ad es. Cass. n. 14149/2012) resta a carico proprio dell'ente creditore.

Va infatti confermato, ancora una volta, l'assunto per cui in tema di riparto dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2067 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma essere titolare del diritto stesso e intende farlo valere (e quindi, nel caso di specie, sull' CP_1 , persino ove sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del diritto contributivo deve essere sempre comprovata proprio dall'ente (Cass. n.19762/2008; Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010, Cass. n. 14965/2012 ecc.).

Certo non è necessario che si sia trattato di attività svolta tutti i giorni (v. la circolare CP_1 n. 78/2013) ma gli elementi ed il parametro in base ai quali riscontrare questa "abitualità, sistematicità e continuità", e comunque la prevalenza, devono essere allegati e provati con idonei e tempestivi mezzi

istruttori e vanno prima di tutto specificate le attività che sarebbero state svolte.

Al contrario ,come si è visto. l CP_1 nemmeno precisa con quale modalità e frequenza sarebbero state svolte queste imprecisate attività proprio da parte di Parte_1 .

In concreto, l' CP_1 non ha indicato, e quindi non ha chiesto di provare, alcuna delle presunte attività che la ricorrente avrebbe posto in essere che il resistente non ha in alcun modo specificato nell'unico mezzo istruttorio richiesto, l'interrogatorio formale della stessa ricorrente ("*Vero che negli anni per cui è causa si occupava della gestione dell'azienda con pieno coinvolgimento abituale e prevalente all'interno della società"*), che risulta, pertanto, palesemente inammissibile.

Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

dichiara l'infondatezza delle pretese di cui all'avviso di addebito CP_1 n. n.397 2022 00254113 80 000;

dichiara, pertanto, che le somme richieste dall *CP_1* non sono dovute;

condanna l'*CP_1* al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2000,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Cirilli antistatario.

Roma lì 24.11.2023 Il GIUDICE

Umberto Buonassisi